

1502132-54.2022.8.26.0302
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/10/2022
... penal. A esse respeito:

"TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
2ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502132-54.2022.8.26.0302
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166520/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 25649912 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2166520 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ
Autor:
Justiça Pública
Réu e Indiciado:
PETERSON ROCHA CAETANO DE BRITO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

PETERSON ROCHA CAETANO DE BRITO está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificado (fls. 190), o réu apresentou defesa (fls. 198/207).

A denúncia foi recebida em 6 de setembro de 2022 (fls. 208/209) e o réu foi citado (fls. 242).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 243).

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado (fls. 243)

e a defesa pugnou pela desclassificação da conduta para a tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 243).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), fotografias (fls. 26/28, 42/51 e 57/68), laudos periciais (fls. 142/145 e 146/156), informação (fls. 158/159), além da prova oral colhida na fase instrutória.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o réu negou a acusação e sustentou que a droga apreendida se destinava ao seu próprio uso. Alegou que conseguiu dinheiro para aquisição das drogas vendendo uma televisão e que fazia três dias que estava fumando pelas ruas sem voltar para casa.

O irmão do réu, Lucas, narrou ter encontrado o acusado fortuitamente e lhe concedido uma carona. Disse que fazia tempo que não o via, pois ele é usuário de drogas e estava "sumido". No momento da abordagem, ele alegou que a droga seria para o próprio uso. A família pretendia interná-lo, mas ele se negava.

O policial militar José Vinícius relatou que estava em patrulhamento quando avistou dois indivíduos, com comportamento suspeito, em uma motocicleta. Durante a abordagem, em revista pessoal, encontrou a droga apreendida com o acusado, que alegou ser para o uso pessoal. Não conhecia o réu anteriormente.

A esposa do acusado, Ana Beatriz, disse que ele estava fazendo uso constante de drogas, todavia se recusava a ser internado.

Como se vê, as provas são suficientes para segura comprovação do crime imputado ao réu.

A versão apresentada pelo acusado não se sustenta.

O policial militar ouvido apresentou narrativa coerente acerca das circunstâncias que motivaram a abordagem do réu. Some-se a isso a considerável quantidade de crack já separada em pequenas porções, além do importe pecuniário destoante de sua condição financeira, visto que ele alegou que estava nas ruas "fumando" há três dias.

No mais, a esposa do réu, ouvida sob o crivo do contraditório, sequer confirmou a venda da televisão mencionada.

Convém lembrar que: "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxima quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (Código de Processo Penal Interpretado, JULIO FABBRINI MIRABETE, 10ª ed., Atlas, 2003, nº 239, pág. 617). E mais: "Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra indícios ou álibi, comprovados, autorizam a condenação" (JTACRESP 51/342).

E o fato de o réu não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal. A

esse respeito:

"TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739.

Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado, que não trouxe elementos a infirmá-lo. E, ainda que ele também seja usuário, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem.

Sobre o tema, veja-se:

"TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)."

Nesta toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado ao acusado restou suficientemente demonstrado.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva do entorpecente apreendido ("crack"), substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, aponto a agravante da reincidência, que é específica (fls. 223 - Proc. 0000342-41.2015.8.26.0598). Assim, majoro a reprimenda de 1/4 para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência do réu enseja o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Assim, a reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando a reincidência e os motivos esposados na primeira fase, a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, CP.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz

natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, “caput”, da CF)”(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a

ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim, por entender que o art. 387, §2º, CPP viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu PETERSON ROCHA CAETANO DE BRITO, qualificado nos autos, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 728 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O acusado respondeu ao processo preso e agora, com maior razão, não poderá apelar em liberdade, tendo em vista que continuam presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente a necessidade de impedir a reiteração criminosa. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Determino o perdimento do valor e do objeto apreendido com o réu, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06.

Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P. I. C.

Jaú, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA